



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1	שורר יעקב, ת.ז. 06911788	תובעים
2	שורר שלהבת, ת.ז. 003983376	
באמצעות ב"כ: עו"ד תירוש אברהם שד' פלי"ם 2 חיפה 33095 טל': 04-8644444 פקס: 04-8673393		
נגד		
1	גת יצחק, ת.ז. 000259580	נתבעים
2	גת אלן מרגרט, ת.ז. 013674916	
באמצעות ב"כ: עו"ד עידן גולדנברג ואח' דרך הים 6, מרכז הכרמל, חיפה טל': 04-8372672 פקס: 04-8102247		

פסק דין

1. עסקינן בתביעה של בעלי דירה בבית דו-משפחתי למתן צו-עשה אשר יחייב את הנתבעים, בעלים של הדירה האחרת בבית, לקיים במלואו את החוזה עליו חתומים תובע מס' 1 ונתבע מס' 1, ולהורות להם לחתום על התקנון המוסכם המקנה לדירת התובעים זכות מעבר ברכב בחלקם של הנתבעים.
2. הבית מושא ההליך נמצא ברח' העמק 26ב, קריית טבעון, ומזוהה כחלקה 105 גוש 11392 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). כל אחד מהצדדים להליך הוא בעלים של דירה בבית: הנתבעים הם בעלי הדירה הקדמית בחלקה; התובעים הם בעלי הדירה האחורית בה. הבית אינו רשום כבית משותף ולא נרשם לגביו הסכם שיתוף.
3. טענות התביעה –
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קריית טבעון אישרה את בניית דירות הצדדים בחלקה. היתר הבנייה שניתן, כולל שני מקומות חנייה מקורים בתווך בין הדירות, ושביל גישה המוביל אליהם.
4. בשל תכנון לקוי של עורכת הבקשה להיתר בניה, תוכנן שביל גישה לא מיטבי לרכבים לחניה שמקשה על התמרון לחניות ומהן. שביל זה כולל בחלקו הראשון שביל אספלט ובהמשכו שביל גנוליט. הרחבת שביל הגרנוליט תאפשר סיבוב נוח ובטוח אל ומתוך חניות הצדדים.
5. בחודש פברואר 1981 נחתם חוזה בין הצדדים במסגרתו חילקו הצדדים ביניהם את החלקה לשימוש ייחודי של כל צד, והקנו לתובע מס' 1 (להלן: "התובע") זכות מעבר בחלקו של נתבע מס' 1 (להלן: "הנתבע") לצורך גישה ברכב לחניה שלו (להלן: "החוזה").
6. תובעת מס' 2 (להלן: "התובעת") ונתבעת מס' 2 (להלן: "הנתבעת") לא נרשמו כבעלים של החלקה ולא חתמו על החוזה, אך כשם שאיש אינו חולק על כך שמכוח הלכת השיתוף הן זכאיות להירשם כבעלים ביחד עם בעליהן, כך יש להחיל עליהן את כל ההתחייבויות בחוזה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. תיקונים שהוספו בכתב יד על גבי החוזה הקנו לתובעים זכות מעבר ברכב בשביל הגישה.
8. הבית נבנה בשנת 1980 ובתחילת שנת 1981 נכנסו התובעים לגור בביתם. רוחב שביל הגישה בתכנית שאושרה בוועדה לתכנון ובניה ביום 8.1.80 עמד על 4 מטרים; תכנית המודד ברמן שבוצעה ביום 21.1.1980 וקיבלה את אישור המודד המחוזי ביום 27.1.85, מדגימה רוחב שביל של 3.2 מטרים.
9. הגישה לחלקה מהרחוב כוללת שביל אספלט שמוצאו ברחוב (להלן: "שביל האספלט"), ובסופו קיימת פניה חדה ממנו לשביל גרנוליט המצוי בניצב לו. שביל הגרנוליט נבנה בשני פסים מקבילים של גרנוליט שהמרחק ביניהם תואם לרוחב גלגלי מכונית והוא נועד לאפשר כניסת רכבים לחלקה. משני עבריו של שביל הגרנוליט קיימת צמחיה ובין שני פסי הגרנוליט קיים ריצוף. שביל הגרנוליט מוביל לחניות הצדדים להליך ולכניסה לדירותיהם (להלן: "שביל הגרנוליט"). שני השבילים גם יחד יכוננו להלן: "השביל".
10. כאשר נכנסו התובעים לגור בבית הם נוכחו לדעת שעקב תכנון לקוי, הגישה לחניה אינה נוחה ונדרש תמרון לא פשוט משביל האספלט לשביל הגרנוליט, ולכן, הם בחרו לחנות רכבם במשך שנים רבות בחלקה הסמוכה בהסכמה שניתנה להם בע"פ על ידי אריך פרידמן, בעל אותה חלקה (להלן: "פרידמן"). הנתבעים התגברו על חוסר הנוחות שבהגעה לחניה באמצעות בניית חניה נוספת בחלק אחר של השטח שעפ"י החוזה שייך להם, באופן שהם אינם נדרשים לעבור ברכב בשביל הגרנוליט.
11. על מנת להימנע מחיכוכים עם הנתבעים הגיש התובע בקשה למתן פסק דין הצהרתי שיקנה לו זיקת הנאה בחלקת פרידמן (שבניתיים נפטר) ויאפשר לו להמשיך להחנות שם את רכבו. לאחר שהובהר לתובע כי סיכויי לזכות בזיקת הנאה נמוכים, הוא נאלץ לחתום על הסכם פשרה עם יורשי פרידמן אשר הקנה לו זכות חניה זמנית בחלקת פרידמן.
12. העובדה שזכות זו עלולה לפקוע בכל רגע, וקיומה של מצוקת חניה ברחוב, הביאו את התובעים להגיש תביעה זו, שנועדה לאפשר להם גישה לחניה שנבנתה עבורם בתחום החלקה.
13. זכות הקניין היא זכות יסוד. על אף שהחוזה טרם נרשם, הוא מחייב את הצדדים לו. התובעים עומדים על מימוש זכות החניה שהוקנתה להם עפ"י החוזה. במקרה הצורך יש להורות על רישום זיקת הנאה מחמת כורח או על ביצוע החוזה בקירוב.
14. החיוב החוזי טרם פקע והסכמים יש לקיים. מכאן שזכותם הקניינית של התובעים למעבר בשטח הנתבעים לא התיישנה ויש לרושמה בלשכת רישום המקרקעין. לאחר רישומה, תהא זכות המעבר ברכב קנויה, בכפוף לחוזה, לכל הנכנס בנעלי התובעים.
15. התובעים מעולם לא ויתרו על זכותם הקניינית. לאורך השנים עמדו התובעים על מימוש זכות המעבר בחלקה ברכב, וזו מתחדשת מיום ליום. אין לזקוף את התחשבותם בנתבעים לחובתם. מכאן שלא מדובר ב"ויתור בהתנהגות".
16. לא יעלה על הדעת שהנתבעים יכירו בחוזה ובה בעת יתכחשו לזכות המעבר ברכב שהוקנתה בו לתובעים. אין לקבל את גרסת הנתבעים שהסכימו לחוזה אולם לא לזכות המעבר.
17. שביל הגרנוליט שנבנה, בטרם הוצר על ידי צמחיה ששתל הנתבע, עומד על 3 מטרים כפי העולה מתכנית מודד מיום 4.4.2018 שהוכנה עבור הצדדים לקראת רישום הבית כבית משותף. צמחיה ששתלו הנתבעים משני צדי שביל הגרנוליט מצמצמת את רוחבו ל- 2.60 מ' בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

18. אשר על כן, יש להורות לנתבעים לקיים את החוזה, לעקור את הצמחייה משני עברי שביל הגרנוליט ולהימנע מלחנות בשביל האספלט, על מנת שלא לחסום את הדרך למעבר רכב של התובעים.
19. לאור הוראת סעיף 11 לחוזה הקובעת כי הוא יחול על כל מי שיבוא במקומו של הצד שמכר את ביתו ו/או העבירו לאחר, יש לקבוע כי מדובר בזכות קניינית (in rem) ולא בזכות אישית (in personam) וכי זו חלה לא רק על הצדדים להליך אלא גם על כל מי שירכוש או יקבל בעתיד את דירתם.
20. טענות ההגנה –
התביעה בגין הפרת החוזה נגועה בשיהוי. פטירת מגישת הבקשה להיתר בניה מזה, וניסיון העדים להתחקות אחר זיכרונותיהם מלפני 40 שנה מזה, מציבים בפני הנתבעים קשיים ראיתיים אותם יש לזקוף לחובת התובעים.
21. יש לדחות את התביעה. ראשית, מהטעם שהזכות החוזית התיישנה. שנית, מהטעם שהיא הליך טקטי הנגוע בחוסר תום לב שעה שהתובעים הסתירו, מחד-גיסא, מסמכים אותם היה עליהם להגיש מכוח תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, ומאידך-גיסא, חשפו תקנון שהינו פרי מו"מ חסוי. אשר על כן מהווה התביעה שימוש לרעה בהליכי משפט המונע את בירורה מכוח דוקטרינת ההשתק השיפוטי.
22. מחוות דעת מומחה שהגישו הנתבעים עולה כי לא ניתן להיעתר לסעד המבוקש ע"י התובעים מחמת סיכון הנשקף להולכי רגל במישור הבטיחותי מחמת נסיעת רכבים בשביל כה צר והצורך להסדיר זכות מעבר בחלקה הסמוכה לצורך תמרון אפשרי בשביל.
23. החוזה אינו עומד בהוראות התב"ע החלה על האזור שהינן תנאי מתלה להתגבשותו. יש לראות את החוזה כבטל מכוח סעיף 27(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן: "חוק החוזים"). אי-חוקיות החוזה מהווה, בנוסף, עילה לביטולו מכוח סעיף 30 לחוק החוזים ומכוח סעיף 158א(ג) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 הקובע שבהעדר שטח תמרון לא ניתן להצמיד לדירה מקומות חניה.
24. התובעים, אשר בחרו שלא להביא חו"ד מטעמם, אינם זכאים לאכיפת חוזה שאינו בר-ביצוע, כפי שמורה סעיף 13(1) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970 (להלן: "חוק החוזים (תרופות)").
25. המזור למצוקת החניה של התובעים אינו מול הנתבעים אלא מול יורשי פרידמן, שבקשו להפסיק את המשך חניית רכבם של התובעים בחלקה שלהם, ולראיה, התובעים הגישו כנגדם תביעה. טענות התובעים בהליך הנוכחי ובהליך שקיימו מול יורשי פרידמן סותרות ואין לאפשר זאת.
26. בין שתי הדירות לא מודגמת חניה. הצדדים מעולם לא החנו את רכבם בתווך בין הבתים. מעולם גם לא ניתן היה להיכנס ל"חניה" באמצעות שביל הגישה. הנטל להציג אישורי חניה שכאלה ממוסדות התכנון רובץ על כתפי התובעים.
27. המוסכים המקורים שהודגמו בתכנית הבקשה להיתר בניה אינם אלא תולדת הצורך לחבר בין הבתים לשם קבלת היתר תכנוני לבניית בית משותף. במקור הוגשה בקשה להיתר בנייה המדגימה שני בתים נפרדים על החלקה ללא חיבור ביניהם, אך זו נדחתה ע"י הוועדה המקומית בנימוק שזה אינו בית דו-משפחתי הדורש חיבור בין הבתים. לאור זאת תכננה עורכת הבקשה את הבתים כך שיחוברו באמצעות חניות מקורות, תוך שהוסכם בין הצדדים כי הם לעולם לא ישתמשו ב"חניות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. על התביעה להידחות מהטעם שהנתבעת אינה חתומה על החוזה, ומשכך הוא אינו יכול לחייבה. לא יהיה זה צודק לפגוע בקניין הנתבעת אשר לא הייתה צד לחוזה. אשר על כן, אין להורות על אכיפת החוזה מכוח סעיף 43(4) לחוק החוזים (תרופות).
29. החוזה לא דווח לרשויות המס ולא שולם בגינו מס ומשכך אין לו תוקף חוקי בהתאם לסעיף 16 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.
30. החוזה מעולם לא נרשם. אם, וככל שהיה לו תוקף, הוא פג זה מכבר במפורש, במשתמע, בהתנהגות ומכללא. תוכנו של סעיף 2 לחוזה, המקנה זכות מעבר לרכב, הוא בלתי חוקי, אסור, פסול, נוגד את תקנת הציבור ומשכך חסר תוקף, ולחלופין, בטל ומבוטל.
31. ככל שיקבע כי יש תוקף לסעיף 2 לחוזה, יש לקבוע כי תוקפו מוגבל לרכב התובעים בלבד.
32. עסקינן בחוזה למראית עין שדינו בטלות מכוח סעיף 13 לחוק החוזים. לחלופין, יש לבטל את החוזה מכוח טעות שטעו הנתבעים לחשוב שהחוזה ישמש לצורך קבלת היתר בניה בלבד לפי סעיף 14 לחוק החוזים.
33. עסקינן בבקשה לפירוק שיתוף על דרך רישום בית משותף. אשר על כן עליה לעמוד מכוח סעיף 38 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") בהוראות חוקי התכנון והבניה. הדין החל על הבקשה לצורך רישום נכון להיום היא תב"ע טב/99 המחייבת שיפוע נמוך מ-16% המודגמים בחלקה לצורך תנועה מנועית בשביל הגישה.
34. צורת החוזה, לרבות השינויים שהוכנסו בו בכתב-ידם של הצדדים, מעידה על אומד-דעת הצדדים שלא לאפשר שימוש מנועי בשביל הגישה אל ה"חניות". פסיקה חדשה של ביהמ"ש העליון שבה ומעניקה את מעמד הבכורה בפרשנות החוזה להגשמת תכלית רצון הצדדים הסובייקטיבית על פני נסיבות כריתתו האובייקטיביות.
35. אפילו נסכין שלתובעים עומדת זכות חוזית, הרי זאת בוטלה מכוח סעיף 36 לחוק החוזים באמצעות התנהגותם. מה גם שמכוח סעיף 41 לחוק החוזים חלף הזמן הסביר לקיומו.
36. הבקשה להיתר הבניה הוגשה ע"י ויקי בנציוני ז"ל טרם שהיא קיבלה רישיון אדריכלות, באופן שהיא לא הייתה רשאית להגיש את הבקשה להיתר בניה או לחתום עליה.
37. יש לסלק את התובענה על הסף, ולחלופין לגופה, ולחייב את התובעים בהוצאות ההליך.

ההליכים בתיק-

38. ביום 21.5.19 וביום 30.10.19 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במהלכם העידו מטעם התביעה: ציון פרץ, מי ששכר את דירת הנתבעים בין השנים 1980-1981, התובע והתובעת. מטעם ההגנה העידו: הנתבע, אלי אסיף, עורך חוות דעת מטעם הנתבעים, חדווה רון, מי שהייתה נשואה לציון פרץ בתקופה בה שכרו את הדירה מהנתבעים, אריה ברנשטיין, נהג מונית, דור בן צבי, אדריכל שהגיש חוות דעת מטעם הנתבעים, אורלי בן שושן, סגנית מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה בקרית טבעון בהווה והנתבעת.

39. הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ, וכעת נותר לי להכריע במחלוקת שלפתיחי.



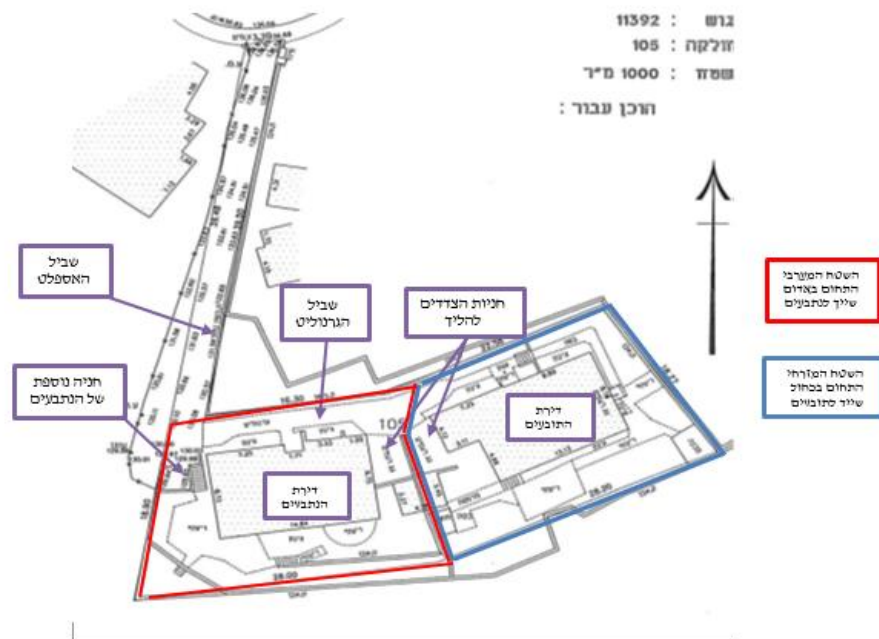
מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון והכרעה-

40. טרם שאכנס לגופה של התביעה, מצאתי לצרף לפסק דיני את תוכנית המדידה של המודד רמזי קעואר אליו פנו הצדדים לצורך הכנת תשריט לרישום בית משותף. על אף שבשל חילוקי דעות שהתגלו בין הצדדים הבית המשותף טרם נרשם, מצאתי לצרפו לפסק הדין על מנת שהעובדות המפורטות בפסק הדין תהיינה נהירות יותר. על גבי התוכנית הוספו על ידי סימונים והערות שלא בהתאם לכללי המדידה התקינה, והתוכנית הועתקה שלא בקנה המידה המצוין בתשריט שהוכן לצורך רישום הבית המשותף.



41. אקדם ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה, הכל כפי שיפורט להלן.

42. אתייחס תחילה לטענות המקדמיות שהעלו הנתבעים ולפיהן חלים על תביעת התובעים התיישנות ומניעות מחמת שיהוי, וכי ההסכם שנחתם אינו מחייב את הנתבעת שעה שהיא אינה חתומה על החוזה ולא קיימת בינה לבין התובעים יריבות.

המסגרת הנורמטיבית לעניין טענת ההתיישנות-

43. סעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן: "חוק ההתיישנות") קובע כי התקופה בה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה במקרקעין מוסדרים עומדת על 25 שנה, וסעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע כי תקופת ההתיישנות מתחילה ביום בו נולדה עילת התובענה. המבחן המקובל למושג "עילת התובענה" לצורך תחילת מרוץ ההתיישנות, הוא "קיומה של עילת תובענה קונקרטית בידי התובע במובן זה שמתקיימות כל עובדות החיוניות הנדרשות לביסוס תביעה שניתן להצליח בה ולזכות" (ראו ע"א 1650/00 זיסר נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נז(5) 166, 177-178 (2003); ע"א 8688/07 רובין נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (פורסם בנבו, 20/12/2010).

44. ככל שמדובר בדיני ההתיישנות, מקובל לפרש את המונח "עילת התובענה" - ואת מועד היווצרותה של עילה כזו - באופן שהוא יבטא לא רק את קיומם של מרכיבי העילה לפי הדין המהותי, אלא גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את קיומם של נתונים נוספים הדרושים כדי שבעל הדין יוכל לפנות לערכאות ולממש בפועל את זכות התביעה הנתונה בידו. עמדה על כך כב' הש' פרוקצ'יה בע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פסקה 20 (פורסם בנבו, 22.6.2008) בצינה כי שילוב מרכיבי התביעה הנדרשים לצורך גיבוש העילה בדין המהותי, ביחד עם אותם נתונים נוספים המכשירים את אפשרות פנייתו בפועל של התובע לבית המשפט, יוצרים את 'כח התביעה' שבידו, אשר עם היווצרותו, מתחיל מניין ההתיישנות לפעול. 'כח תביעה' כאמור, פירושו קיום אפשרות ממשיית להגיש תביעה ולזכות בסעד המבוקש, באם יעמוד התובע בנטל ההוכחה העובדתי, ובנטל הביסוס המשפטי של תביעתו.

45. כן ראו את הדברים שנקבעו בע"א 8438/09 רובאב חברה לנכסים נק אחים דונץ (פורסם בנבו, 19/4/2012), מפי כב' הש' עמית:

"מועד לידתה של עילת התובענה לצורך מירון ההתיישנות, הוא המועד שבו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על ידי הנתבע. במילים אחרות, מירון תקופת ההתיישנות מתחיל ביום שבו אילו היה מגיש התובע תביעתו לבית המשפט והיה מוכיח את כל העובדות המהותיות- היה זוכה בפסק דין".

בפסק הדין עמד כב' הש' עמית על טעמים העומדים בבסיס דיני ההתיישנות, כדלהלן:

"על הטעמים העומדים בבסיס דיני ההתיישנות הדיונית עמדתי בעניין הוועדה לאנרגיה אטומית, ואזכיר להלן את עיקרי הטעמים, והם: טעם ראיתי הקשור בקושי ובהכבדה על הנתבע לשמור את ראיותיו לאורך זמן, שכן דרכו של עולם שבחלוק השנים מסמכים הולכים לאיבוד, עדים מאבדים את זכרונם וכו'; אינטרס הנתבע לוודאות בדבר זכויותיו וחובותיו, כך שיוכל לכלכל את צעדיו ללא חשש שמא ייתבע בגין שנים עברו; ריח מחילה וויתור, באשר תובע "הישן על זכויותיו" תקופה ארוכה מבסס אצל הנתבע ציפיה כי לא ייתבע; ושיקול מערכתי מנקודת מבטה של מערכת המשפט, אשר ראוי שתקדיש את משאביה לעניינים שבהווה ולא לעניינים שאבד עליהם הכלח, כאשר קציבת תקופת ההתיישנות מתמרצת תובעים להגיש תביעתם במועד ולא בחלוף שנים רבות..."

המסגרת הנורמטיבית לענין טענת השיהוי-

46. סעיף 27 סיפא לחוק ההתיישנות קובע כי חוק ההתיישנות אינו בא לפגוע בכל סמכות לפי כל דין, "לדחות תובענה או לסרב למתן סעד מחמת שיהוי". תנאי לפגיעה בזכותו של תובע בגין שיהוי, הוא שהנתבע סבל מנזק בשל השיהוי, זאת ללא הסבר המניח את הדעת לסיבת השיהוי בהגשת התביעה. בע"א 5110/05 מינהל מקרקעי ישראל נ' שטיינברג (פורסם בנבו, 18.1.2007) סקר כב' הש' רובינשטיין את התנאים שנדרשים להתקיימותו של שיהוי המצדיק דחייתה של תובענה, בראי הפסיקה כדלהלן:

"... לימים נקבע בסעיף 27 לחוק ההתיישנות תשי"ח-1958 כי אין החוק בא לפגוע, בכל סמכות, לפי כל דין, לדחות תובענה או לסרב סעד מחמת שיהוי"; ... בע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעיה נ' בית טלטש בע"מ, פ"ד נד(5) 252 ראה השופט קדמי את השיהוי כעילה לדחיית תובענה, אם נתבטא בו ויתור על הזכות מצד התובע, ומצב הנתבע הורע (עמ' 281); ראו גם דברי השופט - כתארו אז - מצא בעמ' 282-283, והשופט דורנר (בדעת מיעוט) בעמ' 286-287. בע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ החיים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ירושלים, פ"ד נז(5) 433 סקרה השופטת פרוקצ'יה בהרחבה את נושא השיהוי בדין האזרחי (עמ' 445-449); כדבריה (עמ' 446)

"לצורך טענת שיהוי נדרש להוכיח כי בנסיבות המקרה זנח התובע את זכות התביעה העומדת לו, או שבמשך הזמן שינה הנתבע את מצבו לרעה. היו שהוסיפו תנאי חלופי שלישי שעניינו שיהוי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנגרם עקב חוסר תום-לבו של התובע... הנטל להוכיח את התנאים הנדרשים לקיום שיהוי מוטל על הטוען לכך, קרי הנתבע". ועוד נאמר: "התנאי בדבר שינוי מצב לרעה של הנתבע אחוז ושלוב בדרישה כי שינוי כאמור ינבע מהתנהגותו הבלתי ראויה של התובע... " ולהלן (עמ' 447) "... וכך, אם נמנע תובע לתובע את זכויותיו במשך זמן ניכר בנסיבות שניתן להבין בהן מכך כי שוב לא יעמוד על זכויותיו, והנתבע הסתמך על כך ושינה את מצבו לרעה, עשויה לעמוד לנתבע טענת שיהוי...". עוד נאמר (עמ' 447-448) כי לבית המשפט שיקול דעת בנושא זה, שהוא אמצעי המופעל אך בנסיבות חריגות, תוך הפעלת שיקולים מורכבים, והשימוש בו "עשוי להיות מוצדק בנסיבות שבהן הדבר מתחייב מטעמים של צדק והגינות כלפי הנתבע, שיקולים שבאינטרס הציבור ודאגה לקיום הליך שיפוטי תקין. לפיכך תביעה לא תיחסם בשל טענת שיהוי כאמור, אלא מקום שהתנאים המוקדמים לכך נתמלאו, ומקום ששיקול הדעת השיפוטי מוביל לכך מטעמים של מאזן הצדק בין הצדדים והשגת תכליות שבאינטרס ציבורי" (עמ' 448).

מן הכלל אל הפרט -

47. הנתבעים טענו כי מדובר בזכות חוזית שלידתה בפברואר 1981 והתביעה בגינה הוגשה ב-10.12.18 כך שהיא התיישנה מכוח הוראת סעיף 5 לחוק ההתיישנות, וכן טענו כי היא נגועה בשיהוי מהותי שגרם להם לקשיים ראייתיים שכן בינתיים נפטרה עורכת הבקשה להיתר בניה, והגב' פרץ (רון דהיום) ועו"ד אלקלעי, שסייע לצדדים בעריכת ההסכם כבר אינם זוכרים פרטים מהותיים.
48. בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק ההתיישנות, במקרקעין מוסדרים תקופת ההתיישנות היא 25 שנים מיום שנולדה עילת התביעה. נדרשת אני, אם כן, לבחון מתי נולדה עילת התביעה.
49. לדידי, עילת התביעה נולדה ביום בו כפרו הנתבעים בקיומה של הזכות לחניה ולמעבר רכבים אל החניה. אבחן להלן מהו המועד בו נודע לתובעים כי הנתבעים **כופרים** בזכותם למעבר רכב בחלקם.
50. בין הראיות שהוגשו לתיק הוגשו שני מכתבים שכתב הנתבע לתובע בעת שהותו בחו"ל, המצביעים על כך שבאותו המועד הנתבע הכיר בקיומן של החניות שנבנו בין הבתים ככאלו שנועדו לשמש כחניות, וכן התייחס לשביל הגרנוליט כשביל שנועד לשמש למעבר רכב. במכתב הראשון מיום 16.6.81, סומן ת/2, כותב הנתבע לתובע: "**בזמנו סיכמתי עם מוסטפה שיזפת גם בחלקה שלי עד המדרגות לדירת המרתף, כלומר נוצרת לי שם חלקה קטנה המיועדת לחניה נוספת**". במכתב ששלח הנתבע לתובע ביום 4.7.81, סומן ת/3, כותב הנתבע לתובע: "**אנא שים לב לשני דברים: 2... אני מעוניין באדמה גם בין המסלולים עבור המכונית בקדמת הבית וגם בין מסלולי הגרנוליט וקיר הבית**". וראו אישור הנתבע בחקירתו הנגדית לכך שמכתב ת/2 נערך בכתב ידו, עמ' 13 לפרוטוקול שורות 24-26, ואישורו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 9-10 לכך שמכתב ת/3 נערך בכתב ידו.
51. עדות נוספת לכך ששביל הגרנוליט תוכנן לשמש למעבר רכבים מצאתי במכתב שהפנה הנתבע ביום 23.5.81 לחברו אליעזר, מי שהיה אמון על טיפול בענייניו הכספיים ובענייני הבניה של הנתבע בעת שהותו בחו"ל, הוגש וסומן ת/12, שם כותב הנתבע: "**אני מאד מעוניין שענין הכביש יסתיים מאחר ולא טוב לדחות זאת לשנה הבאה ושנית המכונית שלי ממש מופקרת מאחר ולא ניתן עכשיו לרדת ולחנות אותה במוסך... לדעתי אין למוסטפה שום case לבקש יותר כסף... הוא גורם לי נזק בזה שלא סיים את עבודת הכביש מאחר וכמו שכתבתי לך, אין אפשרות להוריד את המכונית שלי למוסך ללא כביש**". בחלקו התחתון של אותו מכתב כותב הנתבע לתובע: "**שלום יעקב, אני שולח לך עותק ממכתב ששלחתי לאליעזר... אני מאד מעוניין לסיים את ענין הכביש... סיכמתי בזמנו עם מוסטפה שהוא יזפת גם בתוך החלקה שלי, כלומר עד המדרגות לדירת המרתף. זה ישמש לי כחניה נוספת**"... (הדגשות אינן במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

52. הנה כי כן, בשלב זה טרם נולדה עילת התביעה שכן הנתבעים טרם התכחשו לזכותם של התובעים להיכנס ברכב לחלק החצר שלהם ולהחנות רכבם בחנייתם. לכך יש להוסיף את העובדה שהתובעים ביכרו באותה העת, מטעמי נוחות, להחנות רכבם בחלקה הסמוכה, ומשכך נמנעו באותו שלב מלהחנות רכבם בחניה שלהם וכפועל יוצא כלל לא ניסו להיכנס לשביל הגרנוליט ברכב.
53. בסביבות שנת 1984 קיימת עדות לכך שהנתבעים ניסו לבצע מקצה שיפורים לגבי היקפה של זכות המעבר והעבירו לתובעים טיוטות של הסכמים שביקשו לחתום איתם, הוגשו וסומנו ת/4 ו-ת/5. לטעמי טיוטות הסכמים אלו אינם מלמדים על כך שהנתבעים כפרו באותה העת בקיומה של זכות הכניסה לחניות ברכב, נהפוך הוא, הם מלמדים על כך שהם הכירו בזכות זו של התובעים ובקשו להגיע להסכמות מטיבות עבורם. הסכמים אלו נדחו ע"י התובעים ולא נחתמו. התובע נשאל בחקירתו הנגדית האם כבר ידע בשנת 1984 על קיומה של בעיה עם החניה והשיב שכן, אך הסביר בהמשך חקירתו כי באותו שלב עדיין ניהלו הצדדים מו"מ ביניהם בעניין: **"כלומר אתה ב-1984 חשבת שיש לך זכות חוזית לעבור עם רכב לחנייה, ידעת שהצד השני לחוזה מתנגד ואתה לא יכול לעשות שימוש בזכות, ומ-1984 ועד התביעה כאן ב-1918 לא הגשת אף תביעה ולא נקטת בהליך משפטי, נכון?"** והתובע השיב: **"לא נכון. לא הגשתי תביעה אבל הליך משפטי ראה המכתבים כגון אלה שהוגשו פה, והיו שיחות בע"פ לאורך כל השנים"**.
54. מתוכם של מסמכים אלו לא עולה אמירה מפורשת של הנתבעים כי הם מסרבים להכיר בזכות התובעים לחנות בחניה שבנו ולהיכנס אליה ברכב, אלא ניסיונות להגיע להבנות לגבי צמצומה של הזכות שהוענקה או התנייתה בתנאים, ומכך בשלב זה לטעמי טרם נולדה עילת התביעה.
55. העדות הראשונה לכך שהנתבעים כפרו בזכות התובעים לכניסה ברכב לחניה מצאתי במכתב ששלחו התובעים לנתבעים ביום 31.8.97, הוגש וסומן ת/6, בו הם דרשו מהם לגזום את הצמחייה שצמחה משני עברי שביל הגרנוליט על מנת שלא תגרם הפרעה למעבר מכונית של התובע למקום החניה שלו. במענה שלח עו"ד אביאל שטרן, ב"כ הנתבעים דאז לעו"ד שילדן, ב"כ התובעים דאז, תשובה אשר לא הוגשה לתיק אך ניתן להבין מה היה תוכנה מהמענה שניתן לה ביום 20.11.97 בו משיב עו"ד שילדן לעו"ד שטרן: **"הוועדה לתכנון ובנייה אישרה את תכניות השכנים לבתיהם, לרבות את מקומות החניה לכלי רכב... אין להעלות על הדעת שמר שורר ייעתר לדרישת שכנו לאיסור חנייה במקום המיועד והמאושר לכך..."**, סומן ת/7.
56. ניתן, אם כן, לראות כי בין אוגוסט לנובמבר 1997 נודע לתובעים כי הנתבעים מתכחשים לזכותם לחנייה בחנייתם ולמעבר ברכב אליה. בחומר הראיות לא נמצאה עדות מוקדמת יותר לסירוב הנתבעים לאפשר לתובעים מעבר עם רכב בחלקה.
57. לטעמי המועד המוקדם ביותר בו נולדה עילת התביעה הוא באוגוסט 1997 עת עלו על שרטון ניסיונות הצדדים להגיע להסכמות לעניין רישום הבית המשותף.
58. מאוגוסט 1997 ועד למועד הגשת התביעה (10.12.18) חלפו כ-21 שנים, ומשכך טרם חלפה תקופת ההתיישנות.
59. מאותם טעמים גם לא מצאתי כי חל שיהוי על התביעה. מחומר הראיות עלה כי מהתנהגות התובעים לא עלה ריח מחילה וויתור. הנתבעים ידעו כי התובעים נמנעים מלממש את זכות המעבר בחלקה לא מתוך ויתור או מחילה אלא מטעמי נוחות גרידא. אין מחלוקת כי מטעמים של תכנון לקוי של שבילי האספלט והגרנוליט התמרון והנסיעה בהם אינם נוחים, ובהינתן שהיה לתובעים פתרון חניה אחר בשנים אלו הם לא מימשו בפועל את זכותם זו. יחד עם זאת, בכל חלופות המכתבים שהייתה בין הצדדים תמיד עמדו התובעים על שימור זכותם זו ולא הסכימו לוותר עליה או לצמצמה. מצב דברים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זה מהווה הסבר מניח את הדעת להימנעותם לעמוד על זכותם זו קודם לכן. ודוקו- אין להלום כי זכותם של התובעים למעבר ברכב בחלקה תתיישן בהינתן שלא מימשו זכותם למעבר ברכב בחלקה מטעמי נוחות, יהיו טעמיהם ככל שיהיו. לדידי, מרוץ תקופת ההתיישנות מתחיל מרגע שכפר הנתבע בקיומה של זכותם זו של התובעים. זאת, בדומה לזכותו של בעלים במקרקעין שהוקנתה לו זכות מעבר ברכב בחלקה אך לא היה ברשותו רכב. אין להלום כי הלה יחשב כמי שהתיישנה זכותו לכניסה ברכב לחלקה בהינתן שבמשך 40 שנים לא עשה שימוש בזכות זו מהטעם שלא היה ברשותו רכב. מירוצה ההתיישנות של זכות התובעים למעבר מתחיל רק מרגע שכפרו הנתבעים באופן מפורש וברור בזכותם זו וללא כל קשר לשימוש שעשו או לא עשו התובעים בשביל עד לאותו מועד.

60. כמו כן, אין להלום כי הנתבעים יהיו רשאים לטעון להסתמכות או לשינוי מצב לרעה בעקבות חניית התובעים בחלקה הסמוכה, שעה התובעים עמדו כל השנים על זכותם לחניה ולמעבר רכב בחלקה בכל המגעים שהיו בין הצדדים.

החוזה אינו יכול לחייב את הנתבעת-

61. אין חולק כי הזכויות בלשכת רישום המקרקעין רשומות עד עצם היום הזה במושע בחלקים שווים על שם התובע והנתבע בלבד. אין גם חולק כי רק התובע והנתבע חתמו על החוזה ת/1, ראו אישור הנתבע, בעדותו בעמ' 12 לפרוטוקול שורות 14-18 וכן בעמ' 13 שורות 7-8, לכך שחתם על החוזה וחתם לצד השינויים שהוכנסו לחוזה בכתב יד. בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 21-22 אישר הנתבע כי מצא את החוזה המקורי שלו אצלו בכספת וכי הוא כולל 2 עמודים ותואם את ת/1.

62. הנתבעים טענו כי לנתבעת מגיעות זכויות בחלקה מכוח חזקת השיתוף, אך לא ניתן לחייב את הנתבעת בהוראות החוזה עליו לא חתמה.

63. מצאתי לדחות טענה זו. הזכויות להן זכאית הנתבעת בחלקה, מכוח הלכת השיתוף, ככל שהיא זכאית להן, כפופות לשעבודים, לחובות ולהתחייבויות החלות על החלקה או על הבעלים הרשומים בה מכוח התחייבות שהתחייב בהן הנתבע. ודוקו- בעל דירה הטוען לזכויות במקרקעין מכוח הלכת השיתוף אינו רשאי לטעון כי משכנתא אשר רשומה על המקרקעין אינה מחייבת אותו היות שהוא לא חתם על מסמכי נטילת ההלוואות, וברי כי הוא זכאי לזכויות במקרקעין בכפוף לשעבודים החלים על המקרקעין. בדומה, הנתבעת אינה יכולה לטעון לזכות במקרקעין הרשומים על שם בעלה הנתבע, אך לא להכיר בהתחייבויות שנטל על עצמו הנתבע בגין המקרקעין. וראו בעניין את ע"א 3563/92 עזבון המנחם מאיר גיטלר ז"ל נ' גיטלר, פ"ד מח(5) 489, 498 (1994) שם נקבע הכלל ולפיו חזקת השיתוף מקימה את ההנחה שכן הזוג הרשום פועל מכוח הסמכה של בן הזוג שאינו רשום, ובהסכמתו, ולכן פעולה שעשה בן זוג בנכס הרשום על שמו בתום לב, מחייבת את בן הזוג השני. וראו גם ע"א 7442/97 עמית נ' עמית, פ"ד נד(4) 625 (2000) וכן בש"א (נצ') 1950/06 נסראללה נ' בנק הפועלים בע"מ (פורסם בנבו, 13.6.2006). האמור מקבל משנה תוקף מקום בו אשרה הנתבעת כי היא ידעה על החוזה עובר לחתימתו, וראו בעניין את תשובתה של הנתבעת בחקירתה הנגדית עת נשאלה האם היא ידעה על החוזה שנחתם בין התובע לבין הנתבע והאם הסכימה עם החוזה: "אז לא קראתי כל כך טוב אז שאלתי כמה שאלות אך הסכמתי עם מה שהיה, אך לא הסכמתי עם מעבר מכוניות", בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 31-37.

ההתחייבויות בחוזה ופרשנותו-

64. אין חולק כי בין התובע לנתבע נחתם בחודש פברואר 1981 חוזה במסגרתו חילקו הצדדים לו את החלקה לשימוש ייחודי של כל צד. בתשריט לעיל הודגמו חלקות הנתבעים והתובעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. השאלה שניצבת לפתחנו עניינה פרשנות החוזה. בית המשפט דן ארוכות ורבות בדבר פרשנותם של חוזים, וביחס שבין לשון החוזה לבין תכליתו כפי שהיא משתקפת בנסיבות חיצוניות לחוזה. בפסיקה נקבע, כי לשון החוזה היא נקודת המוצא לכל הליך פרשני. **"ככל שלשון החוזה מצביעה באופן בהיר על אומד דעתם של הצדדים בעת כריתת החוזה, שמורה לה הבכורה בהליך הפרשני"** (ע"א 7186/15 בורשטיין נ' שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות בע"מ, פסקה 17 (פורסם בנבו, 3.9.2019); ראו גם: ע"א 841/15 פנורמה הצפון חברה לבנייה בע"מ נ' פלוגי, פסקה 10 (פורסם בנבו, 23.5.2016). ברוח זו קובע סעיף 25(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (כפי שתוקן בתיקון מס' 2 לחוק משנת 2011) כי: **"חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות העניין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו"**, ראו גם: ע"א 1536/15 פז חברה נפט בע"מ נ' תחנת דלק חוואסה בע"מ, פסקה 46 (פורסם בנבו, 8.2.2018).

66. כן נקבע בפסיקה שככל שאין בלשון החוזה כדי להוביל למסקנה ברורה, על הפרשן להתחקות אחר אומד דעת הצדדים מתוך בחינת הנסיבות החיצוניות לחוזה. בתוך כך, יש ליתן הדעת להתנהגות הצדדים במסגרת המשא ומתן שהביא לכריתת החוזה, להתנהגותם במהלך הוצאתו לפועל של החוזה, להתנהלות הצדדים בשנים שלאחר החוזה, ולנוהג המקובל בעניין (ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD, פסקה 42 (פורסם בנבו, 6.9.2017).

67. בע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ (פורסם בנבו, 20.11.19) (להלן: **"ביבי כבישים"**) התייחס בית המשפט להלכה ששלטה בכיפה בהתאם לע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, פ"ד מט(2) 265 (1995) (להלן: **"הלכת אפרופים"**) אשר קבעה כי חוזה יש לפרש, בראש ובראשונה, לפי תכליתו הסובייקטיבית, ובאין אפשרות לקבוע את תכליתו הסובייקטיבית של החוזה על ידי התחקות אחר כוונות הצדדים, על בית המשפט לפרש את החוזה לפי תכליתו האובייקטיבית, וקבע, כי לא נכון להחיל גישה פרשנית זו בכל חוזה וחוזה היות ש"לא כל החוזים נולדו שווים". בפסק דינו ציין בית המשפט כי רמת הפירוט של החיובים והזכויות איננה זהה בכל חוזה וחוזה, ישנם חוזים פתוחים שנדרשת השלמתם וחוזים סגורים עם תניות מלאות וברורות שהוגדרו באופן ברור ונהיר. ישנם חוזים שנערכו בין צדדים שווים ואחרים בהם הצדדים לו אינם שווים ולא נכון להפעיל כללי פרשנות זהים לכולם.

68. בענייננו מדובר על חוזה פרטי בין שני בעלי דירות שאמנם נעזרו לצורך עריכתו בעו"ד משותף (עו"ד אלקלעי), אך ביצעו בו שינויים ותוספות בכתב ידם, מחקו בו סעיפים רבים וניכר בו שההסכמות גובשו בצוותא חדא ע"י שני צדדים. בעניין זה נכון, לדידי, להפעיל את כלל הפרשנות הנותן משנה תוקף ללשון החוזה. את הרציונל למתן עדיפות ללשון החוזה במקרה של חוזה פרטי היטיב לתאר כב' השופט גרוסטקוף בפס"ד ביבי כבישים כדלהלן:

"כלל פרשנות מרכזי התורם לשכלול ההתקשרות החוזית, הוא כלל הנותן ללשון החוזה מעמד מכריע בהליך פרשנות החוזה. יתרונו של כלל זה הוא בכך שהוא מקנה לצדדים במועד הכריתה שליטה מוגברת על תוכן החוזה, באמצעות כלי הניסוח שברשותם, תוך הבטחה כי הפרשן המוסמך (בית המשפט) יפעל על פי הנחיותיהם הכתובות, ולא ינסה לנחש את העומד מאחוריהם לאחר שהתגלע סכסוך ביניהם. ודוק, הצדדים חשופים במקרה זה לסיכון של טעויות בניסוח, במובן זה שאם הניסוח בו יבחרו לא יתאם את כוונתם לא תוענק להם רשת ביטחון שיפוטית שתתקן טעות זו, ואולם הם מונעים מעצמם את הסיכון שצד שלישי (הפרשן המוסמך) יקרא לתוך החוזה, מתוך חוכמה שבדיעבד, את אשר הצדדים לא ביקשו לכתוב לתוכו."

69. אבחן להלן האם לשון החוזה יכולה להעיד על כוונת הצדדים. לצורך כך אביא להלן את סעיפים ג2 ו-11 מהחוזה שהם הסעיפים הרלוונטיים לענייננו:



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

2.	2.
2.	2.

11. חרזה זה יוטעם בלשכת רישום המקרקעין אוֹלָם אי רישומו לא יפגע בהחזירה והחזירה לטעם חרזה זה, והחזרה חרזה זה י יתחילו על כל מי שיבחר במקומו על הנד שמכר את ביתו ר/או והקבירו לאחר.

71. הנתבעים מנגד טענו כי יש לפרש את החוזה לאור אומד דעת הצדדים והנסיבות שהביאו לכריתתו. לטענתם, החניות שהודגמו בהיתר הבניה תוכננו רק בשל דרישת הוועדה המקומית ליצור חיבור בין הבתים על מנת להפוך אותם לבית משותף. לטענתם, סעיף 2 לחוזה הינו למראית עין בלבד ונועד לאפשר את רישום הבית כבית משותף, שכן מקום בו נרשם בית ככולל 2 חניות קיימת חובה להקנות זכות גישה לחניות אלו ברכב. בפועל, לטענתם, החניות לא נועדו לשמש לחניה, ומשכך, לצדדים לא הייתה כל כוונה להקנות לתובעים זכות כניסה ברכב לחלקה.

עמוד 11



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זכות מעבר דרך חלקו של הנתבע, אולם, ההקניה למעבר ברכב תהיה רק לרכב משפחת התובע. בסעיף 11 לחוזה נקבע כי הזכויות מכוח החוזה יחולו גם על מי שיקבל/ירכוש את דירת התובע.

73. בנסיבות דן לשון החוזה ברורה ואינה משתמעת לשתי פנים, ועולה ממנו זכות מפורשת למעבר ברכב של משפחת התובע בחלקו של הנתבע בהתאם לסעיף ג2. בהתאם לסעיף 11 לחוזה, זכות זו אינה זכות אישית לתובע בלבד אלא היא תחול גם על כל מי שיקבל או ירכוש את דירתו.

74. די באמור כדי לקבוע כי לשון החוזה תומכת בעמדת התובעים כי הם זכאים לזכות מעבר ברכב בחלקם של הנתבעים.

75. למעלה מן הצורך, אוסיף ואבחן את אומד דעת הצדדים כפי שהיא נלמדת מתוך הנסיבות החיצוניות לחוזה. זאת, ככל שניתן לייחס ללשון הוראת סעיף 2 לחוזה מספר משמעויות, ובכללן כוונת הצדדים שלא להפעיל את הזכות שהוקנתה לתובע בסעיף ג2 לחוזה.

76. בפסיקה נקבע כי אומד דעתם של הצדדים משתקף גם מהתנהגותם בשנים הרבות שחלפו לאחר כריתת החוזה. בית המשפט עמד לא פעם על כך שהתנהגותם של צדדים לאחר כריתת חוזה משמשת כלי פרשני לבחינת כוונתם בעת ההתקשרות בחוזה ויש בה כדי ללמד על האופן שבו הבינו את תוכנו. ראו בין היתר: ע"א 376/76 פקיד השומה ירושלים נ' אריזדה, פ"ד ט (1), פסקה 4 (1976); ע"א 49/06 שניר תעשיות צמר גפן רפואי בע"מ נ' עירית כפר סבא, פסקה 8 (פורסם בנבו, 10.6.2008):

"ההתנהגות לאחר כריתתו של חוזה מלמדת כיצד הצדדים לו הבינו אותו. אם צד לחוזה נהג בדרך מסוימת שיש בה כדי להצביע כיצד הוא מפרש את הוראותיו, יתקשה הוא לטעון בהמשך כי פרשנותו של החוזה שונה היא" (וראו עוד: ע"א 7259/15 לביא נ' אורקי בניה שירותים והשקעות בע"מ, פסקה 10 (פורסם בנבו, 17.1.2017); ע"א 439/85 חברת הרשפינקל ובנו בע"מ נ' גולדשטיין, פ"ד מב(1) 286, 292 (1988); בג"ץ 932/91 קרן הגימלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה, פ"ד מו(2), 430, 437-438 (1992)).

התנהגות הצדדים עובר לכריתתו של החוזה-

77. כפי שצוין לעיל, המחיקות וההוספות שבוצעו על גבי החוזה והנוסח הסופי שנחתם מלמדים על כך שהתובעים עמדו על כך שתוקנה להם זכות מעבר ברכב לחנייה.

התנהלות הצדדים בשנים שלאחר חתימת החוזה-

78. התובעים העידו כי בסמוך למועד בו נבנה הבית הם נכנסו מעת לעת לחניתם, ראו סעיף 4 לתצהיר התובעת וסעיף 12 לתצהיר התובע. הנתבעים הכחישו טענה זו וטענו כי התובעים מעולם לא חנו בחנייה מושא ההליך. הנתבע העיד כי משנת 1982 לא נסע אף רכב על גבי שביל הגרנוליט, ראו סעיף 29 לתצהיר עדותו הראשית.

79. למשמע העדים מצאתי להעדיף בעניין זה את גרסת הנתבעים ולפיה התובעים לא עשו מעולם שימוש בחנייה שבנו כפי שיפורט להלן: ראשית, מר פרץ העיד מטעם התובעים כי בתקופה שהוא שכר את דירת הנתבעים התובעים חנו, מעת לעת, בחניתם (סעיף 3 לתצהיר עדותו הראשית). עד זה הוא לכאורה עד ניטרלי, שכן, כפי שהעיד בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 11-2, אין לו יחסי קרבה כלשהם עם התובעים, והוא נותר ביחסים טובים גם עם הנתבעים מהם שכר למשך שנה את הדירה. יחד עם זאת, בעדותו של עד זה נמצאה סתירה. העד הצהיר בסעיף 3 לתצהירו כי בתקופה בה שכר את הבית מהנתבעים הוא חנה בחנייתם. אך מנגד הודה בחקירתו הנגדית כי רכבם של הנתבעים, אוטוביאנקי ירוקה, חנתה בחניית הנתבעים בתקופה ששכר את הנכס. שתי הגרסאות אינן עולות בקנה אחד, שכן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהינתן שרכב מסוג אוטוביאנקי ירוק חנה בחניית הנתבעים עת שהו בחו"ל, ממילא לא יתכן שמר פרץ חנה בה באותה התקופה, וראו עדותו בעניין בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 26-21. שנית, בתרשומת שערך התובע לבא כוחו ביום 15.8.18 כותב התובע: **"ב 1.4.1981 נכנסנו לגור בביתנו החדש, ברח' העמק 26' ונוכחנו שבגלל תיכנון לקוי- הגישה לחנייה קשה לתימרון, ולכן התחלנו לחנות על מגרש סמוך של החלקה 77 גוש 11392"**. מתרשומת זו עולה כי התובעים החלו לחנות בחלקה הסמוכה החל ממועד אכלוס הדירה. בתרשומת אין כל אזכור לכך שמעת לעת חנו התובעים בחניה בתוך החלקה. התרשומת הוגשה וסומנה נ/2. וראו גם סיכום דברים שערך התובע ביום 18.2.19 בו הוא מציין: **"40 שנה אנו מתחשבים בפרופ' גת ומשפחתו לא נוסעים מול הבית שלהם, ולא נכנסים לחניה שלנו כי רוצים להתחשב בהם..."**, הוגש וסומן נ/3. בשני המסמכים שנכתבו ע"י התובע אין אזכור לכך שהתובעים חנו בחנייתם מעת לעת.

80. האם הימנעות התובעים מלהיכנס עם רכב לשביל הגרנוליט ולהחנות רכבם בחנייתם מעידה על כך שאומד דעת הצדדים הייתה כי לא ייעשה שימוש בשביל הגרנוליט ובחניות?

לעניין אומד דעת הצדדים והמשמעויות שיש ליחס להתנהגותם בשנים שלאחר חתימתם על החוזה יש להפנות לדברים הבאים-

81. הנתבע בעדותו לא ידע להסביר את הרקע לחתימתו על סעיף ג2 לחוזה שהקנה לתובעים זכות מעבר בחלקו ברכב. בתצהיר עדותו הראשית הסביר כי נעשו תיקונים בכתב יד בחוזה ש"אינני יודע היום לשחזר איך נולדו השינויים האלה". וכן ציין- **"במועד זה לא הבנתי את המשמעות של מעבר ברכב על פני שביל הגישה הצמוד לחזית דירתי"**. בסעיף 22 לתצהירו משער העד מדוע חתם על החוזה: למיטב הבנתו כנראה שהדבר נדרש על מנת שיתאפשר לרשום את הבית המשותף, היות שהחניה המתוכננת חייבה הדגמת זכות גישה אליה, וראו עדות הנתבע בעניין בעמ' 17 לפרוטוקול שורה 18: **"אני הבנתי שזה נעשה ואני חוזר ואומר לצרכי רישום בפנקס הבתים המשותפים בלבד"**. בחקירתו בעמ' 1 לפרוטוקול מיום 30.10.19 שורות 8 ואילך לא הצליח העד להסביר מדוע החיבור בין הבתים לא נעשה באמצעות מחסן שלא היה דורש זכות מעבר ברכב אליו.

82. כפי שעלה מחומר הראיות, הנתבעים נסעו לתקופת שליחות בחו"ל בזמן שעדיין בוצעו עבודות בניה בבית. בין הראיות שהוגשו לתיק הוגשו שני מכתבים שכתב הנתבע לתובע בעת שהותו בחו"ל, אשר יכולים ללמד על כוונת הצדדים לכך שהחניות שנבנו בין הבתים ישמשו בפועל כחניה. במכתב הראשון מיום 16.6.81, סומן ת/2, כותב הנתבע לתובע: **"בזמנו סיכמתי עם מוסטפה שיזפת גם בחלקה שלי עד המדרגות לדירת המרתף, כלומר נוצרת לי שם חלקה קטנה המיועדת לחניה נוספת"**. במכתב ששלח הנתבע לתובע ביום 4.7.81, סומן ת/3, כותב הנתבע לתובע: **"אנא שים לב לשני דברים: 2... אני מעוניין באדמה גם בין המסלולים עבור המכונית בקדמת הבית וגם בין מסלולי הגרנוליט וקיר הבית"**, וראו אישור הנתבע בחקירתו הנגדית לכך שמכתב ת/2 נערך בכתב ידו, עמ' 13 לפרוטוקול שורות 24-26, ואישורו בעמ' 14 לפרוטוקול שורות 9-10 לכך שמכתב ת/3 נערך בכתב ידו.

83. עדות נוספת לכך שהחוזה או הסעיף לא היו למראית עין ואכן הייתה כוונה שהשביל ישמש למעבר רכבים מצאתי במכתב שהפנה הנתבע ביום 23.5.81 לחברו אליעזר, מי שהיה אמון על טיפול בעניינים הכספיים וענייני הבניה של הנתבע בעת שהותו בחו"ל, הוגש וסומן ת/12, שם כותב הנתבע: **"אני מאד מעוניין שענין הכביש יסתיים מאחר ולא טוב לדחות זאת לשנה הבאה ושנית המכונית שלי ממש מופקרת מאחר ולא ניתן עכשיו לרדת ולחנות אותה במוסך... לדעתי אין למוסטפה שום case לבקש יותר כסף... הוא גורם לי נזק בזה שלא סיים את עבודת הכביש מאחר וכמו שכתבתי לך, אין אפשרות להוריד את המכונית שלי למוסך ללא כביש"**. בחלקו התחתון של אותו מכתב כותב הנתבע לתובע: **"שלום יעקב, אני שולח לך עותק ממכתב ששלחתי לאליעזר.. אני מאד מעוניין לסיים את**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ענין הכביש... סכמתי בזמנו עם מוסטפה שהוא יזפת גם בתוך החלקה שלי, כלומר עד המדרגות
לדירת המרתף. זה ישמש לי כחניה נוספת..." (הדגשות אינן במקור)

84. חיזוק לכך שהשביל נועד לשמש לכניסת רכבים אני מוצאת גם בעדות תובעת מס' 2, סעיף 6 לתצהיר עדות ראשית מטעמה, ובעדות התובע מס' 1, סעיף 10 לתצהירו, כי השביל נסלל כשהוא כולל שני פסי גרנוליט שהמרחק ביניהם כמרחק שבין צמיגי רכב והוא ממשיך ממש לתוך החניות, וראו גם את תמונות ת/14 ו-ת/15 בהן נראה שביל גרנוליט שבנוי משני פסי גרנוליט מרוחקים (מחומר הראיות עלה כי במקור בין פסי האספלט הייתה קיימת אדמה ורק בהמשך רוצף השטח בין פסי הגרנוליט בריצוף).

85. תוכן מכתבי הנתבעים בסמוך לאחר חתימת החוזה והאופן בו בחרו לסלול את שביל הגרנוליט מלמדת על אומד דעת הצדדים להסדיר להם ולתובעים זכות מעבר ברכב לחלקה.

86. לאור האמור, לאחר בחינת לשון החוזה ואומד דעת הצדדים, דעתי היא כי כוונת הצדדים הייתה להקנות לתובעים זכות מעבר ברכבם בשביל אל החניה.

87. טענות נוספות שהעלו הנתבעים הן שהחוזה פקע או בטל מחמת שלא נרשם, שהוא נוגד את תקנת הציבור, שנחתם למראית עין ועוד.

החוזה חסר תוקף היות שלא נרשם או לאור התנהגות הצדדים-

88. את טענת הנתבעים כי החוזה לא נרשם ומשכך הוא אינו מחייב יש לדחות מהטעם שהתובע והנתבע שהם צדדים להליך הם אותם הצדדים שחתמו על החוזה, ומשכך ברי כי הוא מחייבם. רישומו של הסכם בין שותפים נועד להקנות לו תוקף מחייב כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכלפי כל אדם אחר, ראו בעניין את הוראת סעיף 29 לחוק המקרקעין.

89. הנתבעים טענו כי מדובר בחוזה למראית עין בלבד ולכן בטל, ולחלופין, כי החוזה ניתן לביטול בהתאם לסעיף 14 לחוק החוזים בשל טעות שטעו הנתבעים לחשוב שזכות המעבר בשביל לעולם לא תמומש והיא הודגמה רק לצורך קבלת ההיתר, וכי החוזה הוא בלתי חוקי היות שאינו עומד בהוראות התב"ע החלה על המקום ולכן בטל לפי הוראת סעיף 30 לחוק החוזים.

90. בפסיקת בתי המשפט נקבע כי, במקרה המתאים, יש לראות הסכם כחוזה שפקע או בוטל באופן משתמע על ידי הצדדים. דוגמא אחת לכך היא פקיעת חוזה מחמת זניחתו. שתיקה, חוסר מעש והעדר כל פעולה לביצוע החיובים הקבועים בחוזה במשך תקופה ארוכה מאוד – עשויים ללמד על כך שהצדדים זנחו את ההסכם. המשמעות של זניחת חוזה על ידי צד עשויה להיות שהוא אף ויתר על זכויותיו על פי החוזה. כלל זה מושרש בפסיקה (ראו: ע"א 156/76 שטרן נ' פרידמן, פ"ד לא(1) 572, 577 (1976) והפסיקה שהובאה שם; ע"א 1901/91 מראות יפו העתיקה בע"מ נ' חברת חלקה 51 בגוש 7060 בע"מ, פסקה 7 (פורסם בנבו, 9.4.1997); ע"א 3991/96 וילוז'ני נ' מעלה השרון (הרצליה) בנין והשקעות בע"מ, פ"ד נב(5) 278, 286-287 (1998)).

91. בנסיבות תיק זה ברי כי הצדדים לא זנחו את החוזה שהרי כל צד להליך עודנו מחזיק באופן ייחודי ומטפח את חלק החצר שהוקנה לו במסגרת החוזה.

92. אפילו הייתי מקבלת עמדתם זו של הנתבעים הפועל היוצא של ביטול החוזה הוא שגם חלוקת שטחי הקרקע בין הצדדים אינה תקפה והחצר כולה, לרבות שביל הגרנוליט, מהווה רכוש משותף. בנסיבות אלו יש לבחון האם מעבר התובעים ברכב בשביל מהווה שימוש סביר ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

93. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים, ראו ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח (1) 645 (1974), ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 824-825 (1974), וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ם, פ"ד לה (4) 77 (1981) שם נקבע כי:

"שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

94. המלומדים והפסיקה עמדו על טיבו של אותו "שימוש סביר" ברכוש המשותף. הגדרה ממצה לשימוש זה מוצאת ביטוי בספרו של פנחס נרקיס הבית המשותף 152 (מהדורה רביעית, שנה), בעמ' 152:

"שימוש כזה יהא שימוש סביר ובלבד שלא ימנע שימוש כזה מבעלי דירות אחרים. "שימוש סביר" הינו סוג של שימוש ברכוש המשותף שעונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף והן על אפשרות הקיום בו בצורה נאותה ומתקבלת על הדעת. שימוש שכזה צריך שיהיה סביר ורגיל לפי תנאי הזמן והמקום".

95. בנסיבות העניין בהן שימוש התובעים בשביל לצורך מעבר כלי רכב אינו מונע שימוש דומה מהנתבעים, עונה על הצרכים הלגיטימיים של בעלי הדירות בבית המשותף ותואם את ייעודו של השביל המוביל אל שתי חניות מקורות אשר נמצאות בתווך בין הבתים, לטעמי השימוש מהווה שימוש סביר.

96. נשאלת השאלה, האם נכון לקבוע כי החוזה שריר וקיים אך התניה המקנה לתובעים זכות למעבר ברכב בחלקה פקעה רק היא מחמת זניחה.

97. בפסיקה נקבע כי לא בנקל ייקבע כי בעל זכות על פי חוזה זנח אותה. יש להצביע על נסיבות מיוחדות, המלמדות כי בעל הזכות ויתר עליה (ע"א 5205/05 שחם שיווק מערכות מיזוג וחימום בע"מ נ' נפ-גל בניין ופיתוח בע"מ, פסקה 13 (פורסם בנבו, 20.3.2008). הודגש כי טענה לזניחת חוזה מבוססת במידה רבה על ממצאים עובדתיים, (ראו למשל: ע"א 10148/05 תדי ירושלים בע"מ נ' כץ-שיבאן (פורסם בנבו, 15.3.2010); ע"א 1047/11 עיזבון המנוח יצחק ברזלי ז"ל נ' המועצה המקומית תל מונד, פסקה 22 (פורסם בנבו, 26.11.2012).

98. לא שוכנעתי כי הנתבעים הוכיחו התקיימותן של נסיבות מיוחדות המצביעות על כך שהחוזה שריר וקיים ורק סעיף ג' לו בטל.

חוזה למראית עין או התקשרות בחוזה בשל טעות-

99. הנתבעים טענו כי יש להחיל על ההסכם את סעיף 13 לחוק החוזים אשר קובע כי **"חוזה שנכרת למראית עין בלבד - בטל; אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה",** או את הוראת סעיף 19 לחוק החוזים הקובעת: **"ניתן החוזה להפרדה לחלקים ועילת הביטול נוגעת רק לאחד מחלקיו, ניתן לביטול אותו חלק בלבד; אולם אם יש להניח שהצד הרשאי לבטל לא היה מתקשר בחוזה לולא העילה, רשאי הוא לבטל את החלק האמור או את החוזה כולו".**

100. בהתאם להוראות סעיפים 13 ו-19 ככל שיקבע כי החוזה כולו, או סעיף ג' לו, נכרתו למראית עין בלבד הפועל היוצא הוא שהחוזה כולו או סעיף ג' בטלים ובעניין זה אפנה לדברים שנקבעו על ידי לעיל בסעיפים 89-93.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/799/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

101. כן טענו הנתבעים כי יש לבטל את סעיף ג2 להסכם מכוח הוראות סעיפים 14 ו-19 לחוק החוזים. הוראת סעיף 14 לחוק החוזים קובעת כדלהלן:

”(א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.

(ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, על פי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת; עשה כן, רשאי בית המשפט לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב כריתת החוזה.

(ג) טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.

”(ד) טעות”, לענין סעיף זה וסעיף 15 - בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.”

102. הנתבעים טענו כי סעיף ג2 לחוזה נכרת רק למראית עין או בעקבות טעות שלהם עת הבינו כי התובעים לעולם לא יעשו שימוש בחניה ובשביל הגישה לכניסת רכבים. לטענתם, במקור תוכנו 2 בתים נפרדים ללא חיבור ביניהם והוועדה לא אישרה תכנון זה. תכנון 2 מקומות החניה המקורים בין הבתים נוצר בעקבות דרישת הוועדה המקומית להצמיד את שני הבתים, ראו עדות הנתבע בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 21-21: **”ההגשה השנייה לפי הצעת המתכננת לבנות שם שני חללים ולקרוא להם חניות, כדי שהבתים יוכלו להיקרא בית משותף נעשתה אך ורק כדי לקבל היתר בניה ולא לשום מטרה אחרת.”**

103. התובעים הכחישו בעדותם את הטענה שקדמה לתוכנית מושא היתר הבניה תכנית אחרת בה תוכנו 2 בתים נפרדים, אך אשרו את הטענה כי החניות תוכנו על מנת ליצור חיבור בין הבתים, ראו עדות התובע בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 1-2, וראו עדות התובעת בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 29-31.

104. בתיק הבניין בוועדה המקומית אין עדות לכך שבמקור תוכן הבית כשני בתים נפרדים ללא חיבור ביניהם, וכי הללו חוברו באמצעות תכנון חניות בתווך בעטיה של דרישת הוועדה המקומית, ראו סעיף 10 לתצהיר הנתבע.

105. הנתבעים אמנם הפנו למכתב ששלח התובע ביום 22.7.79 לוועדה המקומית בו נכתב: **”כיון שצורת המגרש רחבה מאד הוצע פתרון של חבור ע”י המוסכים, כשהם חלק אינטגרלי מהמבנה השלם”** אך, לדידי, לא ניתן ללמוד מהמכתב כי תכנון המוסכים נעשה למראית עין בלבד ולא על מנת שהצדדים ישתמשו בהם, אלא ניתן ללמוד ממנו, לכל היותר, כי חיבור הבתים באמצעות מוסכים היה צורך תכנוני שהיטיב עם מגישי הבקשה להיתר.

106. כשנשאל הנתבע בעדותו מדוע חתם על השינויים המפורטים בסעיף ג2 לחוזה השיב: **”הוסבר לנו כנראה למיטב זכרוני ע”י עו”ד אלקלעי שערך את החוזה שמאחר ובתשריט מצוינות חניות המפקחת על הבתים המשותפים לא תאשר את החלוקה אם לא תהיה דרך שם, זה נעשה רק לצרכי הרישום בלי כוונה”**, ראו עמ' 12 לפרוטוקול שורות 27-30.

107. לא מצאתי לקבל את גרסת הנתבע כי הסכמתו למתן זכות מעבר לתובע ברכב נעשתה למראית עין בלבד או מתוך טעות ואי הבנה של משמעות חתימתו על החוזה. ראשית, מעיון בהתכתבויות שהוחלפו בין הצדדים התרשמתי כי הנתבע שהוא אדם משכיל, פרופ' בהכשרתו, יודע ומבין היטב על מה הוא חותם ואף מקפיד לרדת לפרטים ולפרטי פרטים במסמכים שהוא עורך, ויעידו על כך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/799/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המכתבים ששלח לתובע בעת שהותו בחו"ל, מוצגים ת/2 ו-ת/3, וכן ההסכמים שהוא ניסח וערך בכתב ידו, מוצגים ת/4 ו-ת/5, שנוצרו מתוך ניסיון להגיע להסכמות שונות מאלו שנקבעו בחוזה. במסמכים אלו מתעבך הנתבע על הפרטים הקטנים, והם אינם עולים בקנה אחד עם המצג של תמימות וחוסר ההבנה אותו ניסה הנתבע להציג בעדותו. בהינתן שזכות המעבר לרכב ניתנה, כפי שהוא טוען, למראית עין בלבד, מתוך הכרח ועל מנת לאפשר את רישום הבית כבית משותף, מצופה היה מהנתבע שידרוש מהתובע לחתום כנגד התחייבותו זו על מסמך נוסף בו מובהר כי זכות מעבר זו לרכב מבוטלת/אינה קנויה לתובע או שיבהיר זאת למן המסמך הראשון שכתב לאחר מועד החתימה על ההסכם, דבר שלא נעשה. שנית, הנתבע, כאמור, סלל את השביל משני פסי גרנוליט שהמרחב ביניהם הוא כמרחק גלגלי רכב ומילא בין פסי הגרנוליט מילוי אדמה, ולא הביא כל הסבר מניח את הדעת מדוע חלף שביל רגיל סלל שביל כאמור, וראו תשובתו בעניין בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 4-8. ראו את עדותה של הנתבעת בעמ' 16 לפרוטוקול שורות 37-39 כי בתחילה הייתה אדמה בין שני פסי הגרנוליט ורק מאוחר יותר הם ריצפו בין הפסים, וראו בעניין גם את עדות מר אסיף, המומחה מטעם הנתבעים, בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 32-36 המאשר כי סלילת שביל משני פסי גרנוליט מראה על כוונת הצדדים כי השביל ישמש לתמרון ולכניסה ויציאה של רכבים:

"ש: תאשר לי שהשביל נמצא בחזית הבית ומוביל לדירות הצדדים עשוי גרנוליט.

ת: נכון.

ש: יש בו שתי הרחבות של הגרנוליט, סומנו בעיגול ובשני עיגולים בתשריט נ/7, והן נועדו לצורך תמרון המכוניות גם בכניסה וגם ביציאה.
ת: על פניו זה נכון וזו הייתה כנראה הכוונה (הדגשות שלי, י"ל).

שלישית, הנתבע לא שלח מעולם הודעת ביטול להסכם, כולו או חלקו, בהתאם להוראת סעיף 20 לחוק החוזים, אלא ביקש לבצע בו מקצה שיפורים באמצעות הסכמים שערך והעביר לתובע, מוצגים ת/4 ו-ת/5, אשר נדחו ע"י התובע.

108. טענה נוספת שהעלו הנתבעים היא כי **"חייב שלא הוסכם על מועד קיומו, יש לקיים זמן סביר לאחר כריתת החוזה..."** כפי שנקבע בסעיף 41 לחוק החוזים. לשיטתם, דרישת התובעים למתן זכות מעבר לרכב בחלקה לאחר כ-40 שנים ממועד כריתת החוזה אינה מהווה קיום בזמן סביר.

109. נשאלת, אפוא, השאלה מהו זמן סביר לאור סעיף 41 לחוק החוזים.

110. בפסיקה נקבע כי המונח **"זמן סביר"** אינו מונח סטאטי, וכי המענה לשאלה מהו **"זמן סביר"** לקיום חיוב שלא נקבע בחוזה מועד לקיומו משתנה ממקרה למקרה בהתאם לנסיבותיו, לרבות התפתחויות המתרחשות לאחר חתימת החוזה, ראו ע"א 464/81 מפעלי ברוך שמיר חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' הוד, פ"ד לז(3) 393, 400-401 (1983); ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון (פורסם בנבו, 9.8.2017).

111. עוד נקבע בפסיקה כי יתכנו מקרים בהם ייקבע שפרק זמן של מספר שנים הינו סביר, ואילו בנסיבותיו של מקרה אחר ייקבע שפרק זמן של מספר חודשים אינו סביר (ע"א 3807/12 מרכז העיר אשדוד ק.א בע"מ נ' שמעון, פסקה 45 לפסק דינו של השופט דנציגר (פורסם בנבו, 22.1.2015)).

112. בנסיבות תיק זה, דעתי היא כי התנהגות התובעים אינה מלמדת על קיום בלתי סביר, ואינה מראה על זניחת התובע את זכותו. ואבהיר- מחומר הראיות עלה כי שביל הגרנוליט שמוביל לחניות שהוקמו אינו נוח במיוחד, וכפועל יוצא גם הנתבעים נמנעו מלהיכנס אליו עם רכב ויצרו לעצמם חניות חלופיות, האחת, בחצר הצמודה להם ושניה בשביל האספלט. התמרון הקשה בשביל, קורת רוחם של הנתבעים מכניסת רכבים אליו והעובדה שלתובעים התאפשר להחנות את רכבם כל אותן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנים בחלקה סמוכה שבבעלות פרידמן ובמיקום קרוב ונוח לביתם, הביאה לכך שהם לא נדרשו לעמוד על אכיפת סעיף 2 לחוזה. ואולם, משנפטר מר פרידמן, הבעלים של החלקה הסמוכה בה חנו, והובהר לתובעים כי סיכוייהם לזכות בתביעתם לקבלת זיקת הנאה בחלקת פרידמן נמוכים, הם חתמו על הסכם פשרה עם יורשיו, המאפשר להם לחנות עוד זמן מה בחלקת פרידמן אך זכות זו יכולה להגיע לקיצה בכל רגע נתון. הפועל היוצא הוא שהתובעים עלולים להיוותר ללא מקום חניה. מנסיבות אלו עולה כי התובעים נמנעו מלאכוף זכותם לכניסה עם רכב לחלקה לא משום זניחה או ויתור על זכותם זו אלא משום שצו השעה לא חייב זאת מבחינתם. בעיני אין הדבר שונה מהותית ממצב בו חוזה מקנה לצד לו זכות גישה לחלקה עם רכב, וזכות זו אינה ממומשת שנים רבות מהטעם שלוכאי אין רכב.

113. לכך יש להוסיף את העובדה שמחומר הראיות עלה שבתכתובת שהוחלפו במהלך השנים בין הצדדים התובעים עמדו לאורך כל הדרך על זכותם זו וסרבו להצעות הנתבע לצמצום זכותם זו. חילוקי הדעות בסוגיה זו גם מנעו את רישום הבית בבית משותף.

מסוכנות השביל והפגיעה שתגרם מנסיכה בו-

114. הנתבעים טענו שהחוזה בטל מחמת היותו נוגד את תקנת הציבור בהיותו מתיר נסיעת רכבים באופן המהווה סכנה בטיחותית לנתבעים

115. מחוות דעתו של אלי אסיף, מהנדס אזרחי, מומחה בתנועה שהגיש חוות דעת מטעם הנתבעים, עלה כי שביל האספלט הקיים בחלקה רוחבו 3 מ' אורכו כ-40 מ' והוא בשיפוע שמגיע עד 20% (סעיף 1.2 לחוות הדעת).

116. בחוות דעתו של האדריכל דור בן צבי, שאף הוא ערך חוות דעתו בעבור הנתבעים, מציין עורך חוות הדעת כי לפי טב-99 במגרש שיש בו שיפוע העולה על 15% שביל הגישה יתאפשר רגלית בלבד ורוחבו המינימלי יהיה 1.5 מ'. לטענתו, בהתאם לתוכנית המדידה של רמזי קעואר ישנם קטעים בדרך העולים על 16% שיפוע. לטענתו, היתר הבניה שניתן אינו תואם לתב"עות תקפות טב-99 וטב-210, ונסיעה בשביל מסוכנת ועלולה לגרום לנזק לגוף ולרכוש. עוד טוען עורך חוות הדעת כי הוועדה המקומית דורשת ממבקש היתר בחלקה עם נתונים דומים לחלקה מושא ההליך להמציא חוות דעת של מומחה בתנועה כתנאי מוקדם לדיון בבקשה להיתר. בהסתמך על חוות הדעת של מומחה התנועה מטעם הנתבעים, ברי כי כיום לא היה ניתן לקבל היתר בניה שיאשר כניסה לחלקה ברכב. המומחה בן צבי, אישר בחקירתו הנגדית כי תכנית טב-99 וטב-210 לא חלו בשנת 1979 עת הוגשה ואושרה הבקשה להיתר בניה, ראו עדותו בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 10-14.

117. משלא הגישו התובעים חוות דעת מטעמם הרי שלא הופרכה טענת הנתבעים לגבי גודל שיפוע הדרך בחלקה. יחד עם זאת, יש לזכור שהיתר הבניה שניתן נבחן בהתאם לתקנים ולהנחיות שהיו קיימים במועד בו ניתן ההיתר ולא ניתן לבחון תקפותו של היתר בנייה ישן לאורם של נהלים ותקנים חדשים שהתקבלו שנים לאחר מכן, וראו אישור המומחה אסיף, עורך חוות הדעת מטעם הנתבעים, לכך שהכללים שנהוגים היום לעניין אישור חניה לא היו נהוגים בשנת 1979, עת אושרה הבקשה להיתר בניה (עמ' 6 לפרוטוקול שורות 42-46), וראו בעניין גם את עדותה של הגב' אורלי בן שושן, סגנית מהנדס הוועדה לתכנון ובניה בקרית טבעון, שאישרה כי בנתונים הקיימים של החלקה כיום לא היה ניתן היתר בנייה המאפשר כניסה ברכב לחלקה זו, אך חדדה והבהירה כי במועד בו ניתן היתר הבניה לא חלו אותן תכניות, וכי רק בסביבות שנת 2012 נכנסה תקנה פנימית שהחמירה את הנהלים לגבי אישור חניה בשיפועי קרקע מעל 15%, ראו עדותה בעמ' 14 לפרוטוקול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/799/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

118. לכך יש להוסיף את העובדה שגם המומחה מטעם הנתבעים אישר בעדותו כי גם שיפוע של 20% לא מהווה מכשול להגיע למקום החניה, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 44-43, וכן העיד בעמ' 6 שורות 20-17 לפרוטוקול: **"הבעיה היא לא השיפוע... אלא רדיוסי הסיבוב, שאינם קיימים"**.

119. לעניין היתכנות הכניסה ברכב לחניה בנתונים הקיימים בחלקה אפנה גם לעדות הגב' שושן, סגנית מהנדס הוועדה המקומית, בעמ' 15 לפרוטוקול שורות 15-14:

"ש: לפי מה שאת רואה בהיתר הבניה, הוועדה אישרה את התכנית ולא נראית מניעה שרכב ייכנס מרח' העמק דרך כביש האספלט ויסתובב כאן לשביל הגרנוליט שקיים פה אל מקום החניה.

ת: על פניו איני רואה מניעה."

כמו כן אפנה לעדות המומחה מר אסיף בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 17-15 שם אישר המומחה כי ניתן לנסוע בשביל בקלנועית, ולא הכחיש את כי רכבים קטנים יכולים לעבור גם כן בשביל ללא בעיה.

120. סיכום האמור מעלה כי כניסה ברכב לשביל בשיפוע כה חד ובנתוני החלקה הקיימים לא היה מאושר כיום אך היה חוקי ותקין במועד בו הוגשה הבקשה להיתר. כן עלה מהעדויות כי אין מניעה להיכנס ברכב לחלקה בשיפוע הנתון אלא שרדיוס הסיבוב בין שביל האספלט לשביל הגרנוליט מכביד ומקשה.

121. לכך יש להוסיף את העובדה שהנתבעים, אשר טוענים לסיכון חיי אדם בעקבות נסיעה בשביל שהשיפוע שלו מגיע ל-20%, עושים בעצמם שימוש בשביל האספלט לשם הגעה ברכב לדירתם ולחניה הנוספת שהם הכשירו לעצמם בתחום החלקה.

122. טענה נוספת שהועלתה בחוות דעתו של אלי אסיף היא שרוחב רכב פרטי טיפוסי הוא 1.66-1.74 מ' (ללא מראות) מה שמחייב את הרחבת שביל הגרנוליט שהינו ברוחב של 1.90 מ', ראו סעיף 2.3.2 לחוות הדעת. לטענתו, ביטול הגינה הקיימת משני עברי שביל הגרנוליט יביא לכך שהרכבים ינועו במרחק של כ-1.5 מ' מדלת ומחלונות דירת הנתבעים, והנסיעה בין גדר החלקה לבין הבית תיצור רעש וזיהום אוויר בדירת הנתבעים, ראו סעיף 2.3.3 לחוות הדעת. גם מר ברנשטיין, נהג המונית שהעיד מטעם הנתבעים, אישר בחקירתו הנגדית, עמ' 10 לפרוטוקול שורות 26-1, כי ניתן להיכנס לחניה עם רכב קטן במיוחד, אלא שלטענתו זה **"סיוט אחד גדול למשפחה שצריכה לגור ולהתנהל בבית פרטי... כשיש סיכוי שרכב ייסע לך על מפתן הדלת..."**.

123. לא מצאתי למנוע, בשל טענה זו, מהנתבעים נסיעה בשביל הגרנוליט. אין ליתן יד לניסיון צד לחוזה להתחמק מהתחייבותו בשל נתונים שהיו ידועים לו עובר לכריתת החוזה והוא בחר, על אף קיומם, לחתום על החוזה. כפי שפורט לעיל, התרשמתי כי הנתבע היה ער להשלכות הנסיעה ברכב בשביל, ובגינן אף ניסה לצמצם זכות זו ככל יכולתו. בסופו של יום אין חולק כי הנתבע חתם על חוזה והתחייב למתן זכות מעבר ברכב בשביל, על אף קרבתו של השביל לביתו. בנסיבות אלו, אין למקום לטעמי להתערב בחופש החוזים ולאפשר לנתבע להשתחרר מהתחייבותו זו.

הקיר-

124. המומחה אסיף אישר כי הסרת הקיר תרווח את המעבר בשביל, ראו עדותו בעמ' 8 לפרוטוקול שורות 26-29.

125. התובע העיד כי אין הכרח לשנות את מיקומו של קיר הלבנים האדומות המצוי בסמוך לכניסה לדירת הנתבעים, ראו עדותו בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 4-2.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/799/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

126. לא מצאתי ליתן צו בעניין הן לאור עמדת התובע והן לאור העובדה שבכתב התביעה עתרו התובעים למתן צו עשה שיחייב את הנתבעים לקיים את החוזה ולאפשר מעבר בשביל אך לא התבקש בו סעד מפורש בעניין הקיר.

חניית הנתבעת בשביל-

127. מחומר הראיות עלה כי הנתבעים חונים רכב אחד בחניה השנייה שהקימו בשטחם ורכב שני הם מחנים בשביל האספלט, ראו אישור הנתבעת בעדותה לכך שהיא חונה בשביל האספלט, עמ' 16 לפרוטוקול שורות 2-10.

128. מחומר הראיות עלה כי חנייה בשביל האספלט תסכל אפשרות הגעה ברכב לחניות.

סוף דבר-

129. מוצאת אני לקבוע כי החוזה, ת/1, שריר, קיים ומחייב. מכוחו זכאים התובעים לזכות מעבר ברגל להם ולבאי ביתם, וכן זכאים הם לזכות מעבר ברכב של משפחת התובעים בלבד. הזכות תחייב את התובעים ואת הנתבעים ותחול גם על מי שיבוא במקומו של צד שימכור או יעביר את זכויותיו בדירה לאחר.

130. אני מורה לנתבעים לגזום את הצמחייה המצויה משני עברי שביל הגרנוליט באופן שמגבול החלקה ועד הבית לא יהיה קיים כל מכשול המפריע לתנועת רכב בשביל. בשים לב להצהרת התובעים, בסעיף 13 לתצהיר התובעת ובסעיפים 47 ו-50 לתצהיר התובע, כי אין בדעתם לעשות שימוש בשביל לצורך כניסה ברכב כל עוד יתאפשר להם להחנות רכבם בחלקת פרידמן, האמור יבוצע בתוך 14 יום מיום קבלת הודעה מהתובעים, שתשלח בדואר רשום עם אישור מסירה, בה מודיעים התובעים לנתבעים מהו המועד ממנו והלאה נמנעת מהם חניה בחלקת פרידמן.

131. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים או על מי מטעמם להחנות רכב בשביל האספלט. צו מניעה זה ייכנס לתוקף בתוך שבוע ימים מיום קבלת הודעת התובעים, כמפורט בסעיף 128 לפסק דיני.

132. אני מורה לרשם המקרקעין לרשום הערה על קיומו של פסק דין בגוש 11392 חלקה 105. ההערה תירשם על זכויות התובע והנתבע ותמחק רק עם רישום תקנון מוסכם לבית המעגן את הוראות החוזה בתוכו.

133. בסעיף 50 לכתב התביעה עתרו התובעים למתן סעד שיחייב את הנתבעים לחתום על התקנון המוסכם שהוכן ע"י בא כוחם. בסעיף 43 לכתב התביעה מציינים התובעים כי התקנון לא צורף לכתב התביעה מהטעם שנערך לצרכי מו"מ בלבד. היות ולא הוגש התקנון המוסכם לחתימה ממילא לא ניתן ליתן סעד המורה לנתבעים לחתום על תקנון מוסכם, מה גם שספק רב אם הסעד מצוי בסמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין.

134. אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובעים, ביחד, בסך של 1,000 ₪ ובהוצאות משפט בסך כולל של 10,000 ₪. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.12.18) ועד התשלום המלא בפועל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/799/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העתק יישלח לצדדים.
ניתן היום, ד' בטבת תש"ף (1.1.20), בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין